

第3節 挙証責任と推定

刑事訴訟法

No222

H18-32

(配点: 3)

月 日

月 日

次の【見解】は、刑事訴訟における当事者の主張・立証活動について述べたものである。後記アからオまでの【記述】のうち、この【見解】の主題を最も適切に述べたものの組合せとして正しいものは、後記1から5までのうちどれか。

【見 解】

検察官は、被告人の有罪を求めて公訴を提起することから、その起訴状記載の公訴事実につき証拠を提出して立証する必要がある。他方、被告人及び弁護人において何らの主張・立証を行わず、検察官の立証の効果を弾効しないならば、結果的に当該公訴事実につき有罪となるおそれがある。

例えば、被害者宅において被害者を殺害して、犯行現場にあった金庫から現金を強取したという強盗殺人事件の公判において、被告人と犯人との同一性に関する証拠が、犯行現場にあった金庫から採取された指紋と被害者宅付近で犯行時刻直後に被告人を目撃した証人の供述であると仮定した場合、検察官が「金庫から採取された指紋が被告人の指紋と一致する。」ことを立証し、被告人が、この点と証人の供述について争わないならば、被告人が犯行時刻ころ犯行現場にいて金庫に触れたことが推認され、これによって裁判官は、被告人の有罪を心証形成するかもしれない。しかし、被告人が、「犯行当日は、犯行時刻直後ころに被害者宅付近を通り掛かったが、被害者宅には入っていない。被害者宅に入ったのは、事件の1週間前の1回だけで、そのとき、金庫に触れたことがある。」旨主張し、検察官と同程度ではないにしても、その主張する事実の立証を遂げたならば、前記のような推認が覆され、これによって裁判官の心証は白紙に戻るかもしれない。その場合、検察官としては、さらに「金庫から採取された指紋は、犯行時刻に被告人が残したものである。」ことを立証する必要がある。

【記 述】

ア. 刑事訴訟における事実認定は、証拠能力を有し、かつ、適式な証拠調べを経た証拠によってなされなければならない。

イ. 証拠調べの過程で、ある事実の存在が一応証明され、又は、その存在に疑いのある状態が生じれば、これによって不利益を受ける当事者に、その存否について立証の必要が生じることとなる。

ウ. 証拠の取捨選択及び事実の認定は、事実審理に当たる裁判所の専権に属するが、それは経験則に反してはならない。

エ. 訴訟における立証活動の事実上の負担は、裁判官の心証形成の推移に応じて当事者間を移動するものであり、これを立証の負担という。

オ. 証拠調べを経て証明すべき事実の存否を判断できない場合、これによって不利益を受ける一方当事者の法的地位を挙証責任という。

1. ア イ 2. イ ウ 3. イ エ 4. ウ エ 5. エ オ

【見解】の主題について

刑事訴訟法において、挙証責任という言葉には2つの意味がある。その1は、証明の必要がある事実について、その存否がどちらとも判然としない場合に、だれが不利益を受けるかという意味である。その2は、手続上実際に証拠を提出しなければならない責任を意味する。前者を実質的挙証責任（客観的挙証責任）、後者を形式的挙証責任（主観的挙証責任）という。

本問の【見解】は、「検察官は、被告人の有罪を求めて公訴を提起することから、その起訴状記載の公訴事実につき証拠を提出して立証する必要がある。他方、被告人及び弁護人において何らの主張・立証を行わず、検察官の立証の効果を弾劾しないならば、結果的に当該公訴事実につき有罪となるおそれがある」として、検察官、被告人のうちいずれが手続上実際に証拠を提出して立証しなければならないかについて述べている。すなわち、形式的挙証責任（主観的挙証責任）について述べている。したがって、本問の【見解】の主題は、形式的挙証責任（主観的挙証責任）である。

【記述】について

ア 最も適切に述べたものではない

317条は「事実の認定は、証拠による」として、訴訟で問題となる事実の存否は、証拠によって決めなければならないという近代裁判の大原則である証拠裁判主義について規定している。しかし、この規定は、右の歴史的意義にとどまらず、犯罪「事実」の認定は、証拠能力及び証拠調べ手続につき法定の資格を備えた「証拠」によること、すなわち犯罪事実には厳格な証明が必要だという趣旨をも表明しているのである。この点、本記述は、このような厳格な証明について述べたものであり、形式的挙証責任（主観的挙証責任）について述べたものではない。したがって、本記述は【見解】の主題を最も適切に述べたものではない。

イ 最も適切に述べたものである

形式的挙証責任（主観的挙証責任）は、挙証（立証）の必要とも呼ばれ、検察官、被告人のうちいずれが現実に証拠を提出しなければならないか、ということであるから、これは、訴訟の具体的状況に応じて、両当事者間を移動する。本記述は、「証拠調べの過程で、ある事実の存在が一応証明され、又は、その存在に疑いのある状態が生じれば、これによって不利益を受ける当事者に、その存否について立証の必要が生じることとなる。」として、訴訟の具体的状況に応じて挙証の必要が両当事者間を移動するとしている。よって、本記述は、形式的挙証責任（主観的挙証責任）について述べたものである。したがって、本記述は【見解】の主題を最も適切に述べたものである。

ウ 最も適切に述べたものではない

318条は「証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。」として自由心証主義を採用することを明らかにしている。自由心証主義が、証拠の証明力の評価を裁判官の自由な判断に委ねるといっても、勝手気ままにどのような判断もできるかという決してそうではない。自由心証主義の方が、法定証拠主義に比べて、実体的真実の発見にとってより合理的であるから採用されているという趣旨に堪え、証拠の評価はあくまで経験則に従った合理的な判断でなければならないとされている。この点、本記述は、このような自由心証主義について述べたものであり、形式的挙証責任（主観的挙証責任）について述べたものではない。したがって、本記述は【見解】の主題を最も適切に述べたものではない。

エ 最も適切に述べたものである

形式的挙証責任（主観的挙証責任）は、挙証（立証）の必要とも呼ばれ、検察官、被告人のうちいずれが現実に証拠を提出しなければならないか、ということであるから、これは、訴訟の具体的状況に応じて、両当事者間を移動する。よって、「訴訟における立証活動の事実上の負担は、裁判官の心証形成の推移に応じて当事者間を移動するものである」とする本記述は、まさに、形式的挙証責任（主観的挙証責任）について述べたものである。したがって、本記述は【見解】の主題を最も適切に述べたものである。

オ 最も適切に述べたものではない

実質的挙証責任は、証明を要する事実に関する証拠が提出し尽くされた後、なお、その事実の存否が真偽不明のときに作用するものである。そして、実質的挙証責任の分配は、訴訟の具体的な進行状況と無関係に証明すべき事項ごとに常に一定している。よって、証拠調べを経ても証明すべき事実の存否を判断できない場合、これによって不利益を受ける一方当事者の法的地位を挙証責任というとする本記述は、実質的挙証責任について述べたものであり、形式的挙証責任（主観的挙証責任）について述べたものではない。したがって、本記述は【見解】の主題を最も適切に述べたものではない。

以上により、【見解】の主題を最も適切に述べたものはイとエであり、したがって、正解は肢3となる。

